

1500276-97.2022.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... a condenação de PEDRO FALCÃO DIAS pelo crime de tráfico de drogas. Por outro lado, resta imperativa a total absolvição de WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAUJO, bem como a absolvição de ambos em relação à imputação de associação para o tráfico.

A materialidade do delito está perfeitamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 52-53), fotografia (fls. 54), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500276-97.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-97.2022.8.26.0288

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085083/2022 - DEL.POL.ITUVERAVA, 23916115 -

DEL.POL.ITUVERAVA, 2085083 - DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAUJO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

PEDRO FALCÃO DIAS e WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAÚJO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput e do artigo 35 c/c. artigo 40, inciso IV (prática visa a atingir adolescente), todos da Lei n.º 11.343/06.

Narra a denúncia que, desde data incerta, mas até o dia 28 de março de 2022, nesta cidade e comarca de Ituverava, PEDRO FALCÃO DIAS e WENDRICK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAÚJO associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 28 de março de 2022, às 16h00, no interior da residência localizada na Rua Antônio Campanela, n.º 321, nesta cidade e comarca de Ituverava,

PEDRO FALCÃO DIAS e WENDRICK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAÚJO, em unidade de desígnios, mantinham em depósito e traziam consigo seis porções de maconha (tetrahydrocannabinol), sendo uma porção grande em formato de tablete e cinco porções menores, acondicionadas em "trouxinhas", pesando 249,98g, e duas pedras de crack (metil benzoil ecgonina), pesando 1,78g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 52-53, laudo de constatação prévia a fls. 56-59 e laudo químico toxicológico a fls. 133-134.

Autuados em flagrante delito, a prisão dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 86-89).

Oferecida denúncia (fls. 164-167), determinou-se a notificação dos acusados para apresentarem resposta à acusação (fls. 170-171).

Defesas preliminares a fls. 184-187 e fls. 203-209.

Recebida a denúncia em 16 de junho de 2022, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 233-235).

Na audiência designada, procedeu-se à oitiva de 04 (quatro) testemunhas de acusação, 03 (três) testemunhas de defesa e, ao final, foram os réus interrogados, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 304).

Encerrada a instrução e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais, respectivamente a fls. 307-321, fls. 326-337 e fls. 338-361.

É, em síntese, o relatório.

fundamento e DECIDO.

Inicialmente, a preliminar invocada pela d. Defesa do corréu WENDRIK, de ingresso policial forçado sem justa causa, não merece prosperar.

Na oportunidade, diante de inúmeras informações dando conta do tráfico de drogas no local, bem como de possível substituição de adolescente, policiais militares em patrulhamento de rotina foram até o imóvel indicado, residência de PEDRO FALCÃO e conhecido "ponto de venda de drogas".

Com a aproximação dos policiais, PEDRO e um adolescente correram, o que levantou suspeitas e autorizou a perseguição, sendo logo abordados e detidos. Durante a perseguição, PEDRO dispensou algo, o que posteriormente foi aferido tratar-se de um tablete de maconha. Com isso, considerando as circunstâncias e informações pretéritas, bem como o claro tirocínio policial, os policiais ingressaram no imóvel, encontrando em seu interior WENDRIK e uma outra adolescente, além do restante dos entorpecentes apreendidos e considerável quantia em dinheiro.

PEDRO e WENDRIK foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas.

Em poder dos réus foram encontradas 06 (seis) porções de maconha e 02 (duas) porções de crack, saltando aos olhos a quantidade do entorpecente maconha, que apresentou peso líquido de 249,98g.

Portanto, a sequência dos fatos não deixa dúvida que os acusados foram abordados e presos em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga

no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão.

Com efeito, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada na residência do réu, cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e sujeita-se às exceções previstas na própria Constituição Federal, como é o caso dos autos, posto que PEDRO e WENDRIK se encontravam em inequívoca situação flagrancial.

Conforme aventado pela d. Defesa em suas alegações finais, não se desconhece a existência de decisões da 6.<sup>a</sup> Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o flagrante hábil a autorizar o ingresso policial, sem mandado judicial, seria apenas aquele que resulta de verdadeira emergência, como nos casos de sequestro, em que há perigo à vida da vítima, não se justificando nas hipóteses dos demais crimes permanentes, como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais.

Contudo, o entendimento que acabou sendo firmado pelo Pretório Excelso é diverso. O *leading case*, que teve inclusive repercussão geral reconhecida, versou exatamente caso de flagrante de tráfico de entorpecentes, após ingresso forçado da polícia em residência, cuja validade acabou sendo reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n.º 280 de Repercussão Geral, observou que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n.º 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015).

Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese da diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito, como no caso em tela.

Nesse sentido, reiterados são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Ilicitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada - Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Desacolhimento - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas" (TJSP; Apelação Criminal 1501177-26.2021.8.26.0571; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2<sup>a</sup> Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022);

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Preliminares - Alegação de inépcia da denúncia - Inocorrência - Questão fulminada pela preclusão - Ademais, peça acusatória que preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP - Nulidade em decorrência de provas ilícitas produzidas a partir de ingresso não autorizado em domicílio - Não ocorrência - Situação flagrancial que prescinde de autorização judicial - Crime permanente, de consumação prolongada no tempo - Presença de fundadas razões para legitimar a conduta dos agentes públicos - Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas nos autos - Depoimentos dos policiais corroborados pelo restante da prova produzida, os quais são dotados de fé-pública - Validade - Ausência de interesse em prejudicar os acusados - Condenação irreparável - Dosimetria - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 -

José Guilherme reincidente específico - Bruna que é primária e foi beneficiada com o redutor em ¼ - Regimes fechado para aquele e aberto para esta que não comportam modificação - Preliminares rejeitadas e recursos defensivos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 1500337-29.2020.8.26.0578; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022);

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição - Nulidade das provas obtidas - Violação de domicílio - Crime permanente - Situação de flagrante a excepcionar a garantia de inviolabilidade do domicílio - Ademais, houve consentimento por parte da genitora do acusado - Provas válidas - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Firmes e seguras palavras dos agentes estatais que, dotadas de fé-pública, não foram desmentidas - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Criminal 1500561-62.2021.8.26.0438; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022);

"PRELIMINAR - nulidade da prova em face da invasão de domicílio - inocorrência - fundada suspeita consistente na visualização do réu em local apontado pela denúncia anônima e com as características indicadas pelo denunciante - fuga do réu após avistar a guarnição policial - guarda de entorpecente que configura estado flagrancial - afastada a preliminar. MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA - depoimento de policiais que indica a apreensão de droga na residência do réu - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - versão do réu de que a residência diligenciada não era sua - versão que não restou demonstrada. TRÁFICO - destinação a terceiros - quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; e denúncia anônima - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. PENA - primeira fase - base fixada no mínimo - manutenção - segunda fase - agravante da reincidência - aumento em 1/6 - 3ª fase - ausentes causas de aumento e diminuição da pena - redutor não reconhecido em face da reincidência - manutenção - improvimento ao apelo REGIME - considerável quantidade de drogas - natureza de parte dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - alta reprovabilidade e periculosidade - reincidência específica - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime fechado - necessidade - detração - não cabimento no presente caso - regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis - substituição da pena reclusiva por restritivas de direito - impossibilidade - alta reprovabilidade - quantum de pena - reincidência específica - improvimento ao apelo" (TJSP; Apelação Criminal 1501914-97.2019.8.26.0571; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022).

Afastada a preliminar, no mérito, a pretensão punitiva estatal comporta parcial procedência, autorizando tão somente a condenação de PEDRO FALCÃO DIAS pelo crime de tráfico de drogas. Por outro lado, resta imperativa a total absolvição de WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAUJO, bem como a absolvição de ambos em relação à imputação de associação para o tráfico.

A materialidade do delito está perfeitamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 52-53), fotografia (fls. 54), laudo de constatação (fls. 56-59) e, em especial, pelo exame químico toxicológico acostado a fls. 133-139, que apontou resultado positivo para a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L (maconha), bem como de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca.

A maconha estava dividida em 06 (seis) porções, na forma de fragmentos vegetais prensados, tipo erva seca, envoltas em segmento plástico transparente, totalizando peso líquido de 249,98g. Já a cocaína estava dividida em 02 (duas) porções, na forma de substância petrificada de cor amarelada, com peso líquido de 1,78g. A apreensão está retratada a fls. 54.

Além do entorpecente, em poder de PEDRO foi apreendida a quantia de R\$ 787,00 e de WENDRIK a quantia de R\$ 56,00 (fls. 116).

A natureza e quantidade da droga, por si só, demonstram sua destinação, não para uso próprio, mas para entrega a consumo de terceiros, caracterizando, assim, o crime de tráfico.

A autoria, por sua vez, é incontestável, ao menos quanto ao corréu PEDRO FALCÃO DIAS, que trazia consigo e mantinha em depósito drogas para o fim de entrega a terceiros.

É certo que todos os envolvidos refutaram o tráfico, alegando apenas o uso compartilhado de entorpecentes.

Contudo, é indubitoso que PEDRO residia no local. Ainda, também é incontroverso que, quando da aproximação dos policiais militares, PEDRO saiu em desabalada carreira, dispensando a porção maior de maconha, conforme retratado a fls. 54.

A forma e quantidade da maconha refutam a singela alegação de uso. Além disso, caso fosse esta a verdadeira destinação, não haveria motivos para que PEDRO fugisse, levando consigo a maior porção do entorpecente.

Na data dos fatos, além dos autuados, dois adolescentes, Isabela Totoli Ferri e Weverton Conegundes Cruz Júnior, também foram encontrados no local.

Ouvidos em juízo, todos apresentaram a mesma versão, com pequenas nuances.

O acusado PEDRO, em seu interrogatório, declarou que "no momento que os policiais entraram estávamos fumando. Nós apavoramos e eu corri. Eu estava com um tijolinho e joguei para o alto e não sei onde foi parar. O Weverton também correu. O droga que dispensei era minha. Dentro da casa tinha mais um pedaço de droga. Não reconheço as pedras de crack encontradas. Quem comprou essa droga foi eu, antes deles chegarem. Comprei numa viela do lado do cemitério. Eu não iria repassar para eles, era só para fumar. Quando pega de monte, pagamos mais barato" (fls. 304).

Desde já, incontroversa a propriedade da droga.

Por sua vez, o corréu WENDRIK, em juízo, refutou a declaração de que "trabalha como traficante", conforme constou em seu interrogatório na fase inicial da persecução penal (fls. 28). Alegou que estava na casa do amigo PEDRO, quando os policiais chegaram. Destacou que "fomos lá para fumar maconha. A polícia chegou e colocou o revólver na minha cara, dizendo que tinha mandado. Eles começaram a fazer busca e nos levou. Fomos usar maconha. O meu amigo Pedro comprou para nós usarmos juntos. Não foi encontrado nenhum cigarro, já tinha até fumado, mas nós passamos o pé, porque lá tem criança. As pedras de crack, eu não vi. A polícia mostrou só a maconha" (fls. 304).

A adolescente Isabela Totoli Ferri também confirmou que estava no local, que é a casa do PEDRO. Declarou que "eu estava junto com o Wendrik, Pedro e Ewerton. Nós estávamos fumando maconha. Nós fomos na casa do Pedro para juntos irmos comprar drogas na biqueira. Mas o Pedro já tinha comprado. Nunca adquirimos drogas do Pedro e do Wendrik. Nós já estávamos fumando e estávamos picando para fumar mais" (fls. 304).

Da mesma forma, o também adolescente Weverton Conegundes Cruz Júnior afirmou que estava no local para fumar maconha. "Quando os policiais chegaram, eu corri. O Pedro também correu. Eu não vi o Pedro dispensar nada. Estava lá para fumar maconha. Nós já tínhamos fumado baseado. Não fomos buscar, o Pedro já tinha buscado. Essa droga, ele foi na biqueira e ele já tinha ido buscar. O Pedro já tinha comprado, pois nós íamos comprar juntos" (fls. 304).

Em que pese o esforço dos acusados e dos adolescentes encontrados no local, não é crível que 249,98g de maconha fosse destinada exclusivamente para imediato uso compartilhado.

Nota-se que nenhum "cigarro" da droga foi apreendido, o que indicaria o uso, apenas 06 (seis) porções grandes do entorpecente, além de 02 (duas) pedras de crack (fls. 54).

Toda a ocorrência foi narrada com detalhes, nas duas fases da persecução penal, pelos policiais militares responsáveis pela autuação em flagrante (fls. 04-05 e fls. 06-07).

Em juízo, o policial militar Renato Moreira da Silva informou que, na data dos fatos, receberam uma delação anônima que no local, casa do PEDRO, ocorria "prostituição de adolescente", além de ser conhecido como "ponto de venda de drogas". Quando se aproximaram da residência, PEDRO e Weverton correram, sendo perseguidos por outros policiais. Diante disso, entrou na casa, encontrando WENDRIK e Isabela em seu interior. Destacou que, "na mesa, havia resquícios de maconha. No momento em que correram, Pedro teria jogado algo ao telhado. No telhado foi encontrado um tijolo de maconha. Nas buscas foram encontradas porções no quarto e mais de R\$ 700,00 em dinheiro". Ainda, afirmou que, abordado, PEDRO confirmou que estaria traficando, além de ser o morador da casa e proprietário da droga. Ao final, asseverou que "nós sabíamos que o Pedro traficava no local, mas a princípio chegou a informação da prostituição de menores. O que nos levantou suspeita foi Wendrik estar no local, pois ele atua no tráfico em outro local distante. Tanto que nos chamou a atenção que o local poderia ser a distribuição de drogas, e ele teria ido buscar ou levar. No local, não havia nenhum cigarro de maconha preparada para uso, mas preparada para comércio" (fls. 304).

Igual teor ostenta o depoimento do também policial militar Jorge Augusto Silva Ferreira, confirmando a informação que motivou a diligência, de que no local "adolescente estaria na prática de prostituição". Com isso, "nós adentramos ao imóvel, por entender que a menor poderia estar sob algum tipo de cárcere. Nesse instante, Pedro já correu e jogou algo no telhado. O Ewerton se escondeu no interior do banheiro. O Pedro afirmou que tudo o que fosse encontrado no local seria dele". Indagado, ressaltou que "não tive dúvidas de que Pedro dispensou parte da droga apreendida". Ainda, informou que "o local já era conhecido como ponto de venda de drogas e que os autuados também eram conhecidos como traficantes, mas sozinhos, não existindo informações de que traficavam juntos" (fls. 304).

As testemunhas de defesa ouvidas nada presenciaram, apenas informando o bom comportamento dos autuados.

Maria Sueli de Moraes Silva é vizinha de PEDRO, declarando que nunca viu nada de errado no local (fls. 304).

Já Paulo Cesar Falcão informou que "Pedro trabalhava com meu cunhado com serviço de pintura e funilaria. Eu desconheço do envolvimento com drogas. Wendrik até me chama de tio. Também desconheço envolvimento sobre drogas dele. Conheço os adolescentes, mas não tenho amizade com eles" (fls. 304).

Por fim, Michele Falcão Dias, mãe de PEDRO, afirmou que "ele é apenas usuário.

Nunca ninguém me falou nada dele vender. Eu não iria aceitar isso. Eu acho que ele usava maconha. Eu não estava no local, por estar trabalhando. O Wendrik, eu o conheço desde criança, eles têm amizade desde criança". Quanto ao dinheiro apreendido, declarou que "foi encontrado dinheiro, setecentos e poucos reais, dos quais quatrocentos reais eram meus. O restante era dele. Esse meu dinheiro é fruto do meu trabalho" (fls. 304).

Portanto, incontroversa a propriedade da droga, a negativa feita pelos réus, quanto à destinação do entorpecente, mostra-se frágil, pueril e inconsistente, diante de todos os elementos de prova carreados aos autos.

Ao menos, muito bem delineada a conduta do corréu PEDRO, que trazia consigo e mantinha em depósito 06 (seis) porções de maconha e 02 (duas) pedras de crack.

PEDRO foi encontrado em sua residência, local em que guardava parte de droga, além de dispensar o restante quando perseguido por policiais militares.

Além disso, pesavam contra o autuado inúmeras informações de que utilizava sua residência como "ponto de venda de drogas".

É certo que no imóvel também foi encontrado o corréu WENDRIK, já conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas. Contudo, em seu poder nada de ilícito foi localizado, apenas a módica quantia de R\$ 56,00. Ainda, nenhuma informação foi apresentada de que PEDRO e WENDRIK estariam desempenhando o tráfico de drogas em concurso, muito menos associados para tal prática.

Ao que tudo indica, WENDRIK e os adolescentes Isabela e Weverton estavam no local em busca de drogas, fornecidas por PEDRO, sem qualquer elemento indicativo do uso compartilhado.

A maconha estava dividida em 06 (seis) porções, sendo uma delas em formato de um grande tablete, pronta para entrega a terceiros e não na forma para imediato uso. O mesmo se diz das 02 (duas) pedras de crack.

Nenhum petrecho para uso de drogas foi apreendido no local, apenas o entorpecente e a quantia de R\$ 787,00, sem qualquer prova da origem lícita.

Observa-se, com isso, que ao menos a negativa de PEDRO, quanto à destinação da droga, está suficientemente afastada pelo restante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao contrário da pretensão formulada pela d. Defesa, o entorpecente não era para uso próprio, mas destinado à venda e entrega a terceiros.

Mesmo que se considere que PEDRO também seja usuário de drogas, conforme por ele propagado, as condições em que foi apreendido permitem a conclusão de que o material tinha outra destinação, ainda que incipiente e com o objetivo de sustentar seu vício, o que de qualquer forma é reprovável.

Caso a droga fosse destinada exclusivamente ao uso, configurando, assim, o crime de porte de entorpecentes ou, até mesmo, o uso compartilhado de drogas, de caráter eventual e sem objetivo de lucro, não estaria o corréu PEDRO trazendo consigo e mantendo em depósito 249,98g de maconha, quantidade absolutamente desproporcional à sua condição, além de razoável quantia em dinheiro, pois ausente prova de ocupação lícita.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, no tocante aos depoimentos de milicianos, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se

apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

Ressalta-se que para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada.

Por fim, considerando as circunstâncias da autuação, não há dúvidas de que PEDRO, assim agindo, visava a atingir adolescente, pois ao menos parte da droga seria fornecida aos adolescentes Isabela e Weverton, incidindo na causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação do corréu PEDRO, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Por outro lado, no tocante ao corréu WENDRIK, os elementos que autorizaram sua autuação em flagrante delito não foram reproduzidos em juízo com a necessária segurança e certeza, de forma que não é possível aferir que ele tenha aderido à conduta criminosa de PEDRO, a configurar o concurso de agentes.

Não se sabe se WENDRIK efetivamente concorreu para o crime de tráfico de drogas ou se estava no local apenas para adquirir ou receber drogas fornecidas por PEDRO.

Diante da fragilidade de provas, a absolvição de WENDRIK resta imperativa.

Da mesma forma, inexistente possibilidade de condenação quanto à acusação de associação para o tráfico.

Para configuração do crime previsto no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, exige-se o dolo específico, vale dizer, um especial fim de agir. É indispensável a intenção de associar-se de forma estável.

Exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1.º, e 34, da Lei n.º 11.343/2006. É necessário que a associação seja estável, identificando-se certa permanência na sociedades criminais, que não se confunde com a mera coautoria.

No caso vertente, não é possível concluir que PEDRO e WENDRIK associaram-se para a prática do tráfico de drogas, sequer existem indícios de que agiam com unidade de desígnios, ficando até mesmo afastada a coautoria ou participação de WENDRIK no crime.

Assim, para a acusação de infração ao disposto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, a absolvição é medida imperativa.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

Inicialmente, observo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como aquelas destacadas no artigo 42, da Lei n.º 11.343/06.

Após a análise dos antecedentes criminais do réu (fls. 79 e fls. 199-202), de sua conduta social e de sua personalidade, levando em conta as circunstâncias e consequências do delito, atento à culpabilidade e ao que seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não vislumbro a necessidade de fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Fixo, pois, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme preceito secundário contido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

O acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o que importa na atenuante previstas no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, deixo de sopesá-la, pois a reprimenda, nesta fase, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Não há agravantes.

Quanto às causas de aumento de pena, reconhecido que o agente visava a atingir adolescente, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que o acusado é primário e não ostenta antecedentes (fls. 79 e fls. 199-202). Além disso, inexistem indícios de que se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (um), 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que tal benesse não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Com o mesmo entendimento:

"Tráfico - Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 - O pedido preliminar para recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final deste voto, por uma questão lógica - Absolvição - Impossibilidade - Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Os depoimentos dos policiais foram firmes em descrever a notícia do delito, a campana, a reação do réu e sua abordagem, bem como o encontro de drogas e de dinheiro - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadão inocente. Não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crimes - Incogitável desclassificar a conduta do acusado para a

prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - É certo que a simples apreensão de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, o flagrante da venda espúria feito pelos milicianos por meio da campana, bem como o encontro de dinheiro dividido em notas diversas e as demais circunstâncias do caso em concreto, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Ademais, a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício - Condenação mantida - Reconhecimento do redutor - Essa causa especial deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime. Sua aplicação se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4º, do artigo 33, da lei em comento, o que ocorre no caso em testilha. E, para calcular a fração de redução de sanção, deve-se levar em consideração a quantidade da droga apreendida com o acusado, a saber 1,7 gramas - Fração de diminuição aplicada no máximo - Pena reduzida - Regime fechado inalterado - Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos - Incogitável - Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal - Não prospera o pedido defensivo para afastar a pena de multa, pois não se vislumbra ofensa ao princípio da proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei nº 11.343/06 - Inadmissível, também, a concessão do benefício da justiça gratuita ao réu, porquanto, a mera alegação de que ele não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse - Recorrer em liberdade - A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Deste modo, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação, bem como, não vislumbro falta de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade - Recurso defensivo parcialmente provido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 500654-61.2019.8.26.0481 - Rel. Freitas Filho - 7.ª Cam. de Direito Criminal, j. 15/05/2020, p. 18/05/2020);

"Apelação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Violação de domicílio - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares - Validade - Condenação mantida - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Admissibilidade diante da grande quantidade e natureza de droga apreendida - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 aplicado na origem - Regime fechado de rigor - Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos - Recurso desprovido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 1500109-15.2019.8.26.0570 - Rel. Roberto Porto, 4.ª Câmara de Direito Criminal - p. 18/05/2020);

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas fixadas com critério - Aplicação do redutor inserto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 devida - Regime semiaberto - Possibilidade - Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei nº 13.964/2019 - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso desprovido" (TJSP - Ap. Crim. n.º 1502993-45.2019.8.26.0302 - Rel. Ricardo Sales Júnior - 15.ª Câmara de Direito Criminal - j. 17/05/2020).

Por força da pena aplicada e da natureza do crime, o regime inicial deveria ser o SEMIABERTO. Entretanto, considerando que o réu está preso há quase 05 (cinco) meses, tendo, portanto, cumprido mais de 1/5 da pena, sem a notícia da prática de qualquer outro crime, excepcionalmente, considerando o caso vertente e atento ao preceituado no artigo 42, do Código Penal e artigo 387, § 2.º, do Código de

Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- a) condenar o réu PEDRO FALCÃO DIAS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO;
- b) ABSOLVER o réu PEDRO FALCÃO DIAS, qualificado nos autos, da acusação de infração ao disposto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- c) ABSOLVER o réu WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAUJO, qualificado nos autos, das acusações de infração ao disposto no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino, ainda, a perda em favor da União da quantia de R\$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), apreendida (fls. 116), pois não ficou demonstrada a sua origem lícita, o que gera a presunção de que o dinheiro se originara da venda efetiva da droga. O restante, quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais), será restituído ao corréu WENDRIK.

Considerando o regime fixado, faculto ao acusado PEDRO FALCÃO DIAS o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Ainda, diante da absolvição, expeça-se imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WENDRIK HENRIQUE FELIPE LIMA ARAUJO.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita, conferidos neste ato.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ituverava, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA